

1502691-39.2022.8.26.0228

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Comarca: SÃO PAULO

Foro: Foro Central Criminal Barra Funda

Vara: 12ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 07/11/2022

... droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA DE SÃO PAULO

Foro Central Criminal Barra Funda

12ª Vara Criminal

Av Dr Abrahão Ribeiro, 313, São Paulo-SP - cep 01133-020

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1502691-39.2022.8.26.0228 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502691-39.2022.8.26.0228

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins (COVID-19)

Documento de Origem:

Inquérito Policial (Flagrante), Boletim de Ocorrência - 2029270/2022 - 33º Distrito Policial - Pirituba, 456/2022 - 33º Distrito Policial - Pirituba

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GUSTAVO DE ALMEIDA GIUZIO e outro

Juiz(a) de Direito: Dr(a). EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Processo n.º 241/22

VISTOS.

GUSTAVO DE ALMEIDA GIUZIO e LETICIA CHAVES BIANCHI, qualificados nos autos, foram denunciados por infração ao disposto no artigo 33, caput e § 1º, inciso II, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, porque consta que, no dia 01 de fevereiro de 2022, por volta das 20h e 30min, na residência situada na Rua Benedito Pereira, 139 - Pirituba, nesta cidade e Comarca, em associação criminosa, cultivavam e tinham em depósito, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, o total de 3.675,1 kg (três quilos, seiscentos e setenta e cinco gramas e uma decigrama) de Tetrahydrocannabinol (THC), vulgarmente conhecida como maconha, ainda em fase de cultivo, as quais, ante as circunstâncias da apreensão, destinavam-se inequivocamente ao tráfico de drogas.
A denúncia foi recebida à fl. 148.

Foram apresentadas defesas preliminares às fls. 164/172 e 176/183.

Durante a instrução processual, foram ouvidas através do sistema de áudio e vídeo, duas testemunhas de acusação, e os réus foram interrogados.

Em memoriais, fls. 231/247, a representante do Ministério Público pugnou pela condenação dos réus nos exatos termos da denúncia por entender bem demonstradas autoria e materialidade dos crimes.

A Defesa de GUSTAVO requereu que o julgamento seja convertido em diligência para que se apure se todas as plantas eram de THC e CDB; exame toxicológico para comprovar a dependência do réu; anulação das provas obtidas ilicitamente, na medida em que os policiais teriam invadido a residência do réu sem mandado judicial de busca e apreensão e que as fotos colacionadas aos autos teriam sido obtidas mediante coação dos agentes públicos. Por fim, pediu que a ação de tráfico de drogas seja julgada improcedente, pois não existem provas suficientes para a condenação.

Por sua vez, a Defesa de Leticia pugnou, preliminarmente, pela absolvição, ao passo que não haveria provas suficientes para embasar um édito condenatório ou, ainda, que a denúncia fosse rejeitada por falta de contexto indiciário adequado.

Subsidiariamente, pediu o reconhecimento do tráfico privilegiado e o direito de a ré recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

Afasto de plano a preliminar arguida pela Defesa do réu, uma vez que a presente ação penal transcorreu de forma legal e regular, nada havendo nos autos, capaz de maculá-la de vício insanável.

E isso porque o laudo pericial foi suficiente em atestar que as substâncias apreendidas nos autos eram positivas para tetrahydrocannabinol.

Todos os demais argumentos lançados pela Defesa do acusado em nada abalam a materialidade delitiva, nem tampouco são capazes de macular a presente ação penal. Com efeito, não há que se falar em nulidade da prisão em flagrante em decorrência de prova ilícita. Fato é que os policiais localizaram grande quantidade de drogas no interior da residência do réu, fato que por si só, já é suficiente a legitimar a ação dos policiais.

Não se ignora os preceitos constitucionais trazidos à baila pela Defesa, segundo os quais a casa é asilo inviolável, a menos que no interior dela esteja ocorrendo um crime, momento em que, a prisão em flagrante mostra-se absolutamente regular, legal e até mesmo necessária.

No sentido pacífico o entendimento jurisprudencial: “Sendo a guarda de narcótico crime de caráter permanente, permitindo a prisão em flagrante – flagrante contínuo – a busca e apreensão, que pode ser realizada até contra a vontade do cidadão, prescinde da existência de mandado” (TJSP – AC 105.973-3/6 – j. 11-12-1991).

E ainda: “A garantia constitucional da inviolabilidade do domicílio admite exceções. Não protege indivíduo em atividade criminosa no recesso da habitação, como é o caso do traficante que esconde maconha dentro de casa. Aí é possível, qualquer que seja a hora, a prisão em flagrante, pois a guarda de substância entorpecente é crime permanente” (TJSC – RT, 508/435).

Com efeito, a materialidade delitiva veio comprovada pelo auto de exibição e apreensão de fls. 129/130, dando conta dos 108 acondicionamentos de maconha, localizados e apreendidos em poder do réu na residência, bem como apetrechos como balança de precisão e iluminação para estufa.

Em complementação, o laudo químico toxicológico de fls. 36/39, atestou que as substâncias apreendidas eram positivas para tetrahydrocannabinol.

A autoria, contudo, somente restou comprovada com relação ao réu, sendo de outra banda, frágil no que diz respeito à participação efetiva da acusada.

A priori, imprescindível analisar que a ré deve ser absolvida de todos os crimes dos quais está sendo denunciada. Isto porque não há qualquer prova nos autos que torne indubitável o seu vínculo com o cultivo das plantas que constituam matéria-prima para a preparação de droga. De tudo que consta dos autos, certo é que LETICIA estava morando por um período na casa do réu e fazia uso esporádico de maconha,

nada mais.

Na fase inquisitiva, fls. 19/20, os réus permaneceram calados.

Em juízo, o réu GUSTAVO declarou que eu sou usuário de maconha, eu faço meu cultivo para meu uso. No dia dos fatos, os policiais chegaram na minha casa e me abordaram quando eu chegava do meu trabalho. Eu deixei eles entrarem na minha casa, mostrei para eles, onde ficava minha estufa, onde eu tinha três pés de maconha e do lado de fora eu tinha mais nove plantas. Tinha também mais três sacos de folhas e galhos. Eu trabalho com carteira assinada. O quite de iluminação era para o cultivo. A balança eu utilizava para ter noção do meu consumo por mês. O ciclo da minha planta dura sete meses. Eu não vendia e nem fornecia. A Leticia morava comigo. Ela fumava da maconha também. Não conhecia os policiais e tenho 27 anos de idade. O cheiro de maconha era bem forte, acredito que por essa razão pode ter havido uma denúncia. Meu irmão tem câncer e usa maconha de forma medicinal.

Em juízo, a ré LETICIA alegou que sou estudante de odontologia na USP e morava no campus da faculdade. Eu passei a ter atritos com minhas colegas de quarto, tornando-se insustentável a convivência. Eu precisava de um lugar para morar, e a casa do Gustavo é grande, ele é meu amigo há muitos anos, nós não somos namorados, apenas amigos mesmo. Ele me convidou para morar na casa dele, até eu encontrar um lugar para morar. Eu não tinha conhecimento das plantações de maconha. Não tinha nada na frente da casa. Todas as plantações estavam no quarto do lado de fora, que ficavam trancados, e eu não ia lá porque eu estava morando de favor. Também nunca senti cheiro nenhum até porque Gustavo fuma cigarro e maconha esporadicamente. Eu fumo maconha esporadicamente também. Eu tenho 23 anos de idade e não conhecia os policiais.

Ocorre, porém, que, enquanto as justificativas da ré não foram de todo afastadas pelas demais provas produzidas sob o crivo do contraditório, os argumentos do acusado não encontraram respaldo nas demais provas dos autos, motivo pelo qual, não convenceram. O réu não apresentou qualquer versão plausível para sua prisão.

Limitou-se a dizer que fazia o uso de maconha e que a enorme quantidade de drogas encontrada não se destinava ao tráfico.

No entanto, a despeito das justificativas apresentadas pelo réu, secundada por sua defesa técnica no sentido de que as drogas seriam para seu uso, sua conduta amoldou-se perfeitamente ao tipo penal descrito na denúncia, sendo a condenação dele portanto de rigor.

O montante de droga apreendida em poder do réu não deixa dúvidas que servia para o tráfico de drogas, eis que a quantidade apreendida, na circunstância, mostra-se absolutamente incompatível com o uso próprio. Além disso, as demais circunstâncias dos autos, tais como, os sistemas de pesagem, iluminação e ventilação, a quantidade de droga encontrada, somado ao relato firme e seguro por parte dos policiais, não deixam dúvidas acerca da traficância.

E mais, o simples cultivo de substância entorpecente por si só, já se enquadra ao tipo descrito na denúncia, não havendo assim que se falar em desclassificação.

Tanto que os policiais civis responsáveis pela prisão dos réus, Alexandre Pereira Fraga e João Carlos de Camargo Silva, ouvidos em Juízo, relataram em uma só voz, de forma firme e segura que nosso titular nos informou que havia uma investigação em curso, ou uma denúncia. Nós fomos ao local, era final do expediente, e cerca de meia hora depois, o réu Gustavo chegou. Ele disse que era a residência dele, informando que tinha apenas um pé de maconha para uso. Ele franqueou nossa entrada, de pronto vimos três pés de maconha na casa, bem como a ré Leticia. Porém, fora da casa, em um quarto, também pertencente à mesma casa, foram encontradas duas estufas bem grande, com luzes e plantas de maconha. Diante de tal fato, ele não teve como negar. Também foram encontradas maconha seca, já colhida, iluminação, balanças. A ré disse inicialmente que não sabia, depois disse que não achava nada de errado. Ela morava na residência também, mas não conseguimos saber se formavam um casal. Reconheceram os réus e não os conheciam anteriormente. Havia um cheiro forte de maconha que não tinha como não perceber.

Os policiais civis narraram com segurança e precisão como se deu a prisão dos acusados, relatando todos os detalhes, desde a chegada ao local em razão de denúncia de tráfico no local, o encontro com o réu GUSTAVO na porta, sua confissão

informal de que plantava maconha juntamente com sua amiga Letícia, o momento em que adentraram o imóvel, o encontro das mudas e apetrechos, a confissão da ré Letícia quanto ao cultivo da droga apenas para uso, até final detenção e prisão.

Mister se faz, neste momento, dizer que o testemunho dos policiais deve ser valorado como de qualquer outra pessoa, não havendo motivo para de pronto depreciá-lo. Há muito já se encontra superado o entendimento de que a fala policial não se prestaria como elemento probatório.

No sentido já se manifestou o STF, quando do julgamento do HC 76.557-RJ, 2ªT., rel. Carlos Velloso, 04.08.1998: "O Supremo Tribunal Federal firmou o entendimento no sentido de que não há irregularidade no fato de o policial que participou das diligências ser ouvido como testemunha. Ademais, o só fato de a testemunha ser policial não revela suspeição ou impedimento."

E ainda: "Como servidores públicos que são, os agentes policiais têm, no exercício de suas funções, a presunção juris tantum de que agem escorreitamente, não estando impedidos de depor sobre os atos de ofício de cuja fase policial tenham participado" (TJ/SP, Ap. 287.216-3, 3ª C., rel. Segurado Braz, 27.01.00).

Além disso, o depoimento dos policiais foi tranquilo, harmonioso e revelou sincronia lógica. Narraram a situação com firmeza, descrevendo as diligências sem qualquer mácula ou eiva de vício a contaminar a prova. Não houve contradição na parte substancial do que disseram na fase policial e em Juízo e eventuais discrepâncias existentes em seus depoimentos, são normais aos relatos prestados por qualquer ser humano, e em nada abalam a condenação.

Tanto é assim que a jurisprudência afirma: "As pequenas contradições decorrem das próprias imperfeições do psiquismo humano, agravadas pelas condições em que a prova é realizada. O testemunho demasiado perfeito, esse, sim é que deve gerar desconfiança" (TACRIM-SP-AP- Rel. Nelson da Fonseca - JUTACRIM-SP 67/311).

Tal a circunstância dos autos. A fala das testemunhas mostrou-se coerente, repita-se e firme desde a fase inquisitiva, narrando com clareza o discorrer dos fatos. Quanto às alegações da Defesa, sobre a ilicitude das provas adquiridas, percebe-se, dos autos, que foi franqueada pelo réu a entrada em sua residência, não cabendo qualquer argumento no sentido de que teria ocorrido a invasão da moradia pelos agentes públicos. Ademais, sobre as fotos colacionadas, conforme explicitado, também não há qualquer caracterização de prova ilícita.

Nem se cogite que a ausência de descrição de ato de venda, compra ou qualquer outro que indicasse atividade de mercancia, pudesse vir a inocentar o acusado da imputação descrita na denúncia. E isso porque, tratando-se de tipo penal tido como de conteúdo múltiplo ou variado, preencheu o réu um dos núcleos do tipo denunciado, sendo, pois, impossível a absolvição.

Para a condenação, na hipótese dos autos, é absolutamente irrelevante não ter sido o agente surpreendido no ato da venda, bastando que haja indicativos outros, como forma de acondicionamento da droga e respectiva quantidade, a indicar a finalidade do tráfico.

No sentido: "Pretendida a desclassificação do art. 12 para o art. 16 da Lei 6368/76 - Inadmissibilidade - Prova robusta no sentido de tipificar o crime de tráfico ilícito de entorpecentes - Irrelevante não ter o apelante sido surpreendido no ato da venda - Forma de acondicionamento da droga em invólucros indicativos de fim de mercancia - Recurso não provido. (Ap. 296.182-3, São Paulo, 4ª C., rel. Canellas de Godoy, 25.04.2000, v.u.).

Em arremate, o fato de o réu ser também usuário e estar cultivando para seu uso. E isso porque como já salientado, o simples ato de cultivar substancias entorpecentes, diga-se nesta gigantesca quantidade, por si só, já é mais do que suficientes para caracterizar o tráfico.

Destarte, não se evidenciou qualquer situação que pudesse excluir o crime ou isentar o réu da pena.

O mesmo contudo não se pode dizer com relação á denunciada. Já com relação a ela, a despeito dos argumentos do Douto Promotor de Justiça, as provas dos autos são frágeis e não suficientes para sustentar o édito de tão grave acusação.

Veja que o local onde o cultivo das substancias era feito, tratava-se da residência

do réu, e nada se comprovou no sentido de que a denunciada tivesse qualquer relação com tal conduta.

Desta forma, havendo dúvidas com relação à conduta da indiciada, outro caminho não há, senão a absolvição dela.

Ademais, mais um reparo merece a peça acusatória. O crime previsto no artigo 35 da Lei de Tóxicos não restou bem demonstrado nos autos. Ocorre que não se comprovou de forma inexorável que os acusados vendiam drogas conjuntamente e de maneira estável. Veja que a ré estava passando apenas uma temporada na casa do réu e, nesse sentido, não se conseguiu provar claramente que os réus atuavam de forma contínua, com tarefas estabelecidas, necessária ao reconhecimento da associação.

Mesmo porque, como já dito, a residência era de propriedade de GUSTAVO, de modo que não há provas contundentes de que LETICIA possuísse vínculo com a droga lá encontrada.

O §1º, inciso II, do artigo 33, da Lei n.º 11.343/2006, restou comprovado. Quem semeia, cultiva ou faz a colheita, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, de plantas que se constituam em matéria-prima para a preparação de drogas, é o caso do réu GUSTAVO.

Passo a dosar a pena.

Verificando as diretrizes do artigo 59 do Código Penal, dolo normal à espécie.

GUSTAVO é primário e não ostenta antecedentes criminais. Assim, fixo a pena base no mínimo legal, 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

Na hipótese dos autos, forçoso de faz reconhecer a incidência da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, §4º, da Lei de Tóxicos. E isso porque o acusado é primário, sem qualquer antecedente, é jovem e não há um indício sequer a demonstrar que faça parte de alguma organização criminosa.

Assim, considerando-se a quantidade de drogas, reduzo a pena base em 1/2, perfazendo 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa.

O valor do dia multa é o mínimo legal.

ISTO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo procedente a presente ação penal, para condenar GUSTAVO DE ALMEIDA GIUZIO, como incurso na pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº11.343/06, a cumprir, em regime inicialmente aberto a pena de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais pagamento de 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, bem como para absolver-lo das penas do artigo 35 da Lei 11.343/06, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP. Julgo, por fim, improcedente a presente ação penal, para absolver LETICIA CHAVES BIANCHI das penas do artigo 33, caput e § 1º, inciso II, e artigo 35, ambos da Lei 11.343/06, na forma do artigo 69, do Código Penal, com fundamento no artigo 386, inciso VII do CPP.

Na hipótese específica destes autos, o regime aberto se justifica tendo em vista que o réu é primário, está trabalhando e não possui qualquer mácula em sua vida. De outro giro, não é possível a aplicação de qualquer substituição, porque o escopo do legislador foi beneficiar delitos que não mantêm repercussão na sociedade, o que não é o caso do tráfico de drogas, cujo promovedor deve ser segregado do convívio social. Não se pode perder de vista ainda, que o artigo 33, §4º da Lei de Tóxicos prevê, de forma expressa a vedação da substituição da pena privativa de liberdade em restritiva de direitos.

É certo que o STF, nos autos do HC 97256/RS, cujo relator foi o Ministro Carlos Ayres Brito, declarou de forma incidental a inconstitucionalidade da vedação em apreço. Mas é certo também que referida decisão foi proferida por maioria apertada (6x4) e reconhecida, apenas na hipótese específica daqueles autos, alcançando tão somente, as partes que ali figuraram.

No mesmo sentido, foi a recente decisão proferida pela 9ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, nos autos da Apelação nº 0090150-57.2012.8.26.0050, cujo teor passo a descrever: "Como bem colocado pelo Ilustre Desembargador Souza Nery: "inviável a aplicação da pena alternativa. Não só pela própria hediondez do crime, que recomenda maior rigor no escarmento, mas

também porque a Lei nº 11.343/06 expressamente veda a benesse aos traficantes, nos precisos termos do que dispõe o seu artigo 44, caput. Tal dispositivo legal foi editado pelos poderes competentes, goza de presunção de constitucionalidade e não parece ofender a Constituição de República de modo franco e direto. Não desconheço que foi reconhecida a inconstitucionalidade desse dispositivo pelo Excelso Pretório (HC 97.256) no ano de 2010, mas essa decisão foi tomada por maioria apertada (6 x 4) e valeu somente para o processo julgado (incidenter tantum)."

Desta forma, não há qualquer declaração de inconstitucionalidade erga omnes, de maneira que, em cada caso concreto, a vedação imposta pela Lei de Tóxicos pode ser aplicada e reconhecida.

Oficie-se à autoridade policial, oportunamente, para incineração do entorpecente apreendido, nos termos do artigo 72 da Lei 11.343/06.

Custas na forma da lei.

P.R.I.C.

São Paulo, 07 de novembro de 2022.

EVA LOBO CHAIB DIAS JORGE

Juíza de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA